

1502308-53.2021.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... irmão, tendo eles confessado a prática do roubo do posto de gasolina.

Concomitantemente, estavam ocorrendo roubos de farmácias, e o depoente estava investigando. Em certa oportunidade, diligenciou na farmácia e a gerente disse que não tinha nada sobre o roubo que o depoente buscava, mas que tinha imagens referentes ao roubo do presente processo. Foram apresentadas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502308-53.2021.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502308-53.2021.8.26.0533

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2231287/2021 - DEL.INV.GER. AMERICANA, 14277439 - DEL.INV.GER. AMERICANA, 1043/20/925 - DEL.INV.GER. AMERICANA, 2231287 - DEL.INV.GER. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

A SE APURAR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de FÁBIO OLIVEIRA MENDONÇA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 1-3):

Consta dos presentes autos de inquérito policial que, no dia 18 de julho de 2020, por volta de 16h30min, na Rua Espanha, nº 402, Jardim Europa, nesta cidade e comarca, FÁBIO OLIVEIRA MENDONÇA, qualificado a fls. 49, agindo previamente ajustado com outro indivíduo ainda não identificado, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a importância de R\$ 230,00, pertencente ao estabelecimento Drogaria Todo Dia, neste expediente representado por Vanessa Rodrigues Montalvão da

Silva.

A denúncia foi recebida (fls. 85-86), o réu apresentou sua resposta à acusação (fls. 135-145), o recebimento foi ratificado e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 146-147).

Em audiência, foram ouvidas as vítimas e testemunhas arroladas e realizado o interrogatório do réu (fls. 200-201).

Na fase do art. 402, foi expedido mandado de intimação para a representante da empresa vítima entregar cópia das imagens de segurança do local dos fatos.

Frustrada a diligência (fl. 205), encerrou-se a instrução (fl. 219).

O Ministério Público apresentou alegações finais na qual pleiteou a procedência da ação nos termos da denúncia (fls. 209-217).

A defesa, por sua vez, pediu a absolvição pela falta de provas para sustentar uma condenação (fl. 222-226).

Vieram os autos conclusos para decisão.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo:

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel mediante violência ou grave ameaça, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída mediante o uso da força efetiva ou potencial direcionada contra outra pessoa com a finalidade de obtê-la para si ou para terceira pessoa, o que constitui seu elemento subjetivo específico. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

O crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. STJ, REsp 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 09/11/2015, Tema 916 dos Recursos Repetitivos.

A existência do crime foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 7-8) e pela prova oral colhida.

A autoria, por sua vez, não restou devidamente comprovada.

Vejamos a prova oral produzida.

A vítima Karolaine Hemile da Silva disse que trabalha na drogaria Todo Dia. No dia estava no caixa junto com Vanessa, sua gerente, quando um homem chegou, anunciou assalto, pediu dinheiro e, após pegar, saiu correndo, sendo perseguido pela gerente. O acusado entrou sozinho na farmácia. O réu não mostrou a arma, só a ponta dela, e depois guardou. A depoente não acompanhou a Vanessa depois que ela saiu da loja, mas Vanessa comentou que havia um carro prata o esperando na rua de trás e que viu o acusado entrando ali. No dia do fato Vanessa foi até a delegacia, e a depoente foi quase um ano depois. Quando foi lá pediram pra ela dizer como ele era e como estava vestido e foram mostradas 4 fotos, mas a vítima não foi capaz de reconhecê-lo. Não consegue reconhecer o réu como o assaltante, não sabe dizer se é ele. Exibido o auto de fl. 20 a vítima disse acreditar que o terceiro é o assaltante. Disse que o assalto durou cerca de 5 a 7 minutos, e o assaltante estava com uma máscara lisa branca.

A vítima Vanessa Rodrigues Montalvão da Silva disse que no dia dos fatos estava próximo ao caixa quando o assaltante entrou pela porta do caixa e anunciou o roubo, portando uma arma. Foi-lhe entregue todo o dinheiro que tinha no caixa e o réu fugiu. A depoente foi atrás do réu, mas não o viu fugir, não viu ele entrando no carro, quem disse isso foram os vizinhos. Ligou para a polícia na hora, e depois

foi na delegacia, não se recorda se no dia do roubo ou alguns dias depois. Na delegacia foi pedido que descrevesse o assaltante e as roupas que ele estava. Foram exibidas as fotos de três pessoas, tendo a vítima reconhecido o réu como o assaltante. Ao ver o réu na audiência virtual o reconheceu como o assaltante, sem sombra de dúvidas. Viu o acusado no dia dos fatos por cerca de 1 ou 2 minutos no máximo. A depoente estava a cerca de 1 metro do caixa. O acusado estava de máscara. Não havia outras testemunhas. Havia filmagem das câmeras de segurança e fotos também.

A testemunha Tiago Moreira dos Reis disse que é policial civil e contou que havia ocorrido um roubo de um posto de combustível, e, neste roubo, foi utilizada uma motocicleta que estava em nome do genitor do réu, sendo que neste roubo houve a participação do réu e de seu irmão. Na época, solicitaram mandado de prisão e busca e apreensão em desfavor do réu e de seu irmão, tendo eles confessado a prática do roubo do posto de gasolina. Concomitantemente, estavam ocorrendo roubos de farmácias, e o depoente estava investigando. Em certa oportunidade, diligenciou na farmácia e a gerente disse que não tinha nada sobre o roubo que o depoente buscava, mas que tinha imagens referentes ao roubo do presente processo. Foram apresentadas as fotos e o depoente percebeu semelhanças com Fábio, autor do roubo no posto de gasolina. Com isso levou a vítima até a delegacia e lá mostrou as fotos do réu ao lado de outras pessoas, e a vítima reconheceu Fábio como o assaltante. A farmácia assaltada inclusive era próxima a residência do acusado, e também próxima ao posto de gasolina que o réu confessou ter assaltado. A vítima reconheceu sem sombra de dúvidas no reconhecimento fotográfico e no reconhecimento pessoal. Não sabe dizer se os prints de tela foram juntados na presente investigação, mas ainda os tem. Os prints eram imagens do sistema de segurança interna. Não se recorda exatamente a data do roubo que possui as imagens, acredita que tenha sido no fim de 2020 ou começo de 2021. Havia uma sequência de roubos nessa mesma farmácia, mas os demais roubos não guardam relação com o ora apurado, pois os indivíduos são fisicamente diferentes, o modo de agir é diferente, os outros roubos eram planejados, cometidos por um indivíduo bem mais alto que Flávio, muito mais organizado. As vítimas disseram que o assaltante estava de máscara. Quando o réu foi apreendido não foi encontrada com ele arma de fogo, e sua prisão se deu em relação ao roubo do posto. As imagens foram solicitadas no formato direto do DVR por conta da resolução, mas a vítima informou que a empresa que controlava o monitoramento mudou, e eles não tinham o contato, até pediu o contato para o superior da vítima, mas disseram que provavelmente dado o lapso temporal já haveriam sido gravadas imagens por cima. O que o depoente tem são prints que foram tirados na época. Há o reconhecimento nos autos feito por fotografia e o reconhecimento pessoal. Reiterou que quando o réu foi reconhecido no presente processo já estava preso pelo roubo do posto, não sabendo dizer se foi questionado para ele onde estaria no dia do crime ora em análise. Ao fim, disse que o roubo do posto foi posterior ao roubo da farmácia. O réu, Fábio Oliveira Mendonça, ao ser interrogado em juízo disse que é pizzaiolo e no dia do roubo da farmácia estava trabalhando. Costumava trabalhar até meia noite em uma pizzaria na Avenida Cillos. Sabe onde é a drogaria, já morou perto, no Jardim Europa, mas na época do roubo não morava mais por lá. Não conhece as vítimas. Conhece o investigador pois o prendeu pelo roubo do posto. Acredita que está sendo perseguido pelo investigador por seu passado. Não sabe como foi reconhecido por uma das vítimas, acredita que possa ser parecido com alguém, não sabe dizer. Nunca confessou o roubo da farmácia. Pois bem.

Após análise de toda a prova colhida, têm-se que as provas contra o réu no presente processo são os reconhecimentos feitos pela vítima Vanessa, de maneira fotográfica, conforme auto de fl. 14-15, reiterado posteriormente via Teams (fls. 43-44) e novamente em audiência.

Ocorre que, a despeito de tal reconhecimento, nenhuma outra prova foi produzida contra o réu, o que impede a superação do standard probatório necessário para a condenação (além de qualquer dúvida razoável).

É certo que o reconhecimento fotográfico pode ser utilizado como meio de prova, notadamente quando realizado seguindo, dentro do possível, as determinações do art.

226 do CPP. Contudo, é necessário que, além do reconhecimento, haja outros elementos probatórios que possibilitem confirmá-lo. Neste sentido, vale observar recente decisão do STJ, que assim entendeu:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDADA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
[...]

2. A jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Reconhecia-se, também, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

3. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

4. Uma reflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, leva a concluir que, com efeito, o reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias", além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).

5. Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato.

6. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

7. Caso concreto: situação em que a autoria de crime de roubo foi imputada ao réu com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico e pessoal efetuado pela vítima em sede policial, sem a observância dos preceitos do art. 226 do CPP, e muito embora tenha sido ratificado em juízo, não encontrou amparo em provas

independentes. Configura induzimento a uma falsa memória, o fato de ter sido o marido da vítima, que é delegado, o responsável por chegar à primeira foto do suspeito, supostamente a partir de informações colhidas de pessoas que trabalhavam na rua em que se situava a loja assaltada, sem que tais pessoas jamais tenham sido identificadas ou mesmo chamadas a testemunhar. Revela-se impreciso o reconhecimento fotográfico com base em uma única foto apresentada à vítima de pessoa bem mais jovem e com traços fisionômicos diferentes dos do réu, tanto mais quando, no curso da instrução probatória, ficou provado que o réu havia se identificado com o nome de seu irmão. Tampouco o reconhecimento pessoal em sede policial pode ser reputado confiável se, além de ter sido efetuado um ano depois do evento com a apresentação apenas do réu, a descrição do delito demonstra que ele durou poucos minutos, que a vítima não reteve características marcantes da fisionomia ou da compleição física do réu e teve suas lembranças influenciadas tanto pelo decurso do tempo quanto pelo trauma que afirma ter sofrido com o assalto.

8. Tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima, deve o réu ser absolvido.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para absolver o paciente.

(STJ - HC: 652284 SC 2021/0076934-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)

A partir deste entendimento, nota-se que os tribunais superiores passaram a adotar maior cautela com os reconhecimentos feitos por vítimas.

Essa exigência de um maior rigor procedimental é explicada pela alta falibilidade do reconhecimento como meio de prova, conforme explicado no paradigmático voto do Min. Relator Rogério Schietti Cruz (HABEAS CORPUS Nº 598.886 - SC, julgado em 27.10.2020), citado no julgado acima colacionado. No referido voto, o Ministro afirma que "o valor probatório do reconhecimento, portanto, deve ser visto com muito cuidado, justamente em razão da sua alta suscetibilidade de falhas e distorções. Justamente por possuir, quase sempre, um alto grau de subjetividade e de falibilidade é que esse meio de prova deve ser visto com reserva".

Vejamos a ementa:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se,

que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, conseqüentemente, de graves injustiças.

6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II).

7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias).

(...)

12. Conclusões:

1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

No voto condutor, Schietti faz minuciosa análise do problema das falsas memórias e exemplifica à exaustão casos de erros judiciários baseados em reconhecimentos equivocados:

"Estudos apontam que o reconhecimento equivocado (mistaken eyewitness identification) tem sido uma das principais causas de erro judiciário, com a consequência – deletéria e muitas vezes irreversível, diga-se – de levar pessoas inocentes à prisão. Dada a evidência de muitos casos de erros judiciais, foi criada nos Estados Unidos, em 1992, a Innocence Project, uma ONG fundada por advogados civilistas, especialistas em pedir indenização ao Estado em decorrência de condenações de pessoas inocentes. Segundo pesquisa feita por essa ONG, aproximadamente 75% das condenações de inocentes se deve a erros cometidos pelas vítimas e por testemunhas ao identificar os suspeitos no ato do reconhecimento. Em 38% dos casos em que houve esse erro, várias testemunhas oculares identificaram incorretamente o mesmo suspeito inocente. (Disponível em: www.innocenceproject.org/.../What_is_the_innocence_Project_How_did_it_get_started.php. Acesso em: set. 2020).

Em 2019, o National Registry of Exonerations – banco de dados que reúne a maior quantidade de informações sobre os casos de erros judiciais já revertidos nos Estados Unidos – apontou que as causas mais frequentes de condenação de inocentes naquele país são: falsa acusação (59%); má atuação das autoridades (54%); erro de reconhecimento – terceiro lugar, representando 29% dos casos (INNOCENCE PROJECT BRASIL. Prova de reconhecimento e erro judiciário. São Paulo. 1. ed., jun. 2020, p. 1).

Os exemplos erros de reconhecimento no Brasil também não são poucos. Cito alguns, apenas para ilustrar algo que se repete com relativa frequência na crônica judiciária.

Em 2014, o ator Vinícius Romão de Souza foi preso, após haver sido reconhecido por uma mulher que o acusou de tê-lo assaltado. Depois de permanecer 16 dias na prisão, a 33ª Vara Criminal do Rio de Janeiro concedeu habeas corpus em favor do acusado, depois que a vítima afirmou, em novo depoimento, que se enganou ao fazer o reconhecimento do ator como o suposto autor do delito.

Reporto, também, o caso de André Luiz Medeiros Biazucci Cardoso, que ficou preso por 6 meses e 26 dias, entre outubro de 2013 e maio de 2014, por sete estupros que não cometeu. Aos 27 anos de idade, foi recolhido no Presídio de Bangu, após uma das vítimas do abuso haver anotado a placa do carro dele e entregue à polícia, afirmando ser o veículo do criminoso. Na delegacia, algumas das vítimas reconheceram André como o estuproador, que chegou a ficar 37 dias na "solitária", sem nenhum tipo de contato exterior. A absolvição, com a consequente liberdade, veio depois de o seu advogado conseguir autorização para feitura de DNA nos resíduos biológicos presentes nas vítimas e nas cenas dos crimes, enquanto ele estava preso. O resultado do teste provou não ser ele o responsável pelos delitos. (Informações obtidas a partir da reportagem publicada no Portal G1: BRITO, Guilherme. 'Aprendi a ter fé', diz inocentado após 7 meses preso por estupros no Rio. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/aprendi-ter-fe-diz-inocentado-apos-7-meses-presos-por-estupros-no-rio.html>. Acesso em: set. 2020).

Registro, ainda, o recente drama vivido pelo violoncelista Luiz Carlos Justino, jovem de 23 anos, preso por engano no centro de Niterói – RJ em 2/9/2020, por um delito ocorrido em 2017. Segundo a acusação, Justino teria praticado um roubo nesse ano, na companhia de mais três pessoas e com emprego de arma de fogo. A participação do referido indivíduo foi determinada por reconhecimento fotográfico, realizado pela vítima ainda em 2017. Em 5/9/2020, o Juiz de primeiro grau converteu a prisão do acusado em domiciliar: "Em termos doutrinários, o reconhecimento fotográfico é colocado em causa em função de sua grande possibilidade de erro. A psicologia aplicada tem se empenhado em investigar fatores psicológicos que comprometem a produção da memória. Neste ramo, encontramos contribuições que dissecam as variáveis que podem interferir na precisão da memória", escreveu o Magistrado. (Informações obtidas a partir da reportagem publicada no site do Correio Braziliense: Músico negro que teria sido acusado por engano é libertado no Rio. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2020/09/4873670-musico-negro-que->

teria-sido-acusado-por-engano-e-libertado-no-rio.html. Acesso em: set.2020)
Faço menção, também, ao caso de Douglas Moreira, que foi preso em janeiro de 2014 - ao voltar para casa depois de plantão realizado no hospital Pan-Americano, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro -, sob a acusação de roubar um carro em Nova Iguaçu, a 39 quilômetros dali. Policiais retiraram uma foto do auxiliar de serviços gerais do seu perfil no Facebook e apresentaram à vítima que, equivocadamente, o reconheceu como sendo o autor do delito (Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/09/20/vida-travadapreso-com-base-em-foto-inocente-fica-ate-3-anos-na-cadeia.htm>. Acesso em: set. 2020).

Por derradeiro, e sem nenhuma pretensão de esgotar os diversos exemplos de afirmados erros de reconhecimento, registro o recente caso de Lucas Moreira de Souza, que chegou a ser condenado a quase 80 anos de prisão, por suposto envolvimento em uma série de assaltos. A Justiça do Distrito Federal, há poucos dias, reverteu a condenação, em razão das inconsistências na investigação: a única prova apresentada contra o então suspeito era um reconhecimento impreciso feito por testemunhas (Disponível em: <https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/10/21/jovem-de-27-anos-e-absolvido-apos-ficar-quase-3-anos-preso-por-crimes-que-nao-cometeu-no-df.ghtml>. Acesso em: out. 2020)".

Diante de tudo quanto afirmado acima, em conclusão, não se pretende aqui desconsiderar por completo qualquer procedimento baseado na memória como meio de prova, até porque o processo penal brasileiro se escora principalmente nas provas testemunhais.

O que se pretende demonstrar, apenas, é que reconhecimentos nem sempre são totalmente confiáveis, sobretudo nas circunstâncias do caso em análise, em que a vítima disse que o assalto durou cerca de 1 minuto, o assaltante estava de máscara no momento do crime, e o reconhecimento foi feito de maneira fotográfica. Tais elementos trazem pouca segurança no reconhecimento por ela feito, e justamente por isso necessitaria ser corroborado por outros elementos, o que não se verificou no caso concreto.

Vale observar que, segundo o relato do investigador de polícia, o réu foi inicialmente ligado ao roubo pela presença de imagens de câmera de segurança no local dos fatos, tendo o próprio investigador notado a semelhança entre o assaltante da farmácia e o réu, que ele já conhecia pois era investigado por outro roubo.

Ocorre que tais imagens não foram juntadas aos autos. Nem as imagens em vídeo, que teriam sido sobrepostas por outras imagens, e nem os prints que foram tirados na época da investigação, que ainda estariam em poder da polícia. Tais provas poderiam corroborar o reconhecimento feito pela vítima, porém não há notícia de sua juntada. Não bastasse, não foi apreendida com o réu arma ou simulacro que pudesse ser reconhecido pela vítima e nem roupas que pudessem ser comparadas com aquelas usadas pelo assaltante.

Além disso, a vítima Karolaine, em 16 de agosto de 2021, durante as investigações, não foi capaz de reconhecer o réu quando confrontada com as imagens de fls. 20-21. É certo que na audiência, mais de um ano depois, apontou o indivíduo de número 3 como o assaltante, porém somente o fez após já tê-lo visto na audiência minutos antes. Difícil imaginar que a vítima não teria reconhecido o réu em agosto de 2021, e agora, ao ver a mesma foto, iria o reconhecer.

Enfim, não há nos autos nenhuma outra prova que possa confirmar o reconhecimento feito pela vítima Vanessa, que, conforme extensamente explicado acima, não possui a confiança necessária para superar o standard probatório exigido para a condenação, de modo que a absolvição é de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para ABSOLVER o réu FÁBIO OLIVEIRA MENDONÇA das acusações que lhe foram feitas na denúncia, nos termos do art. 386, VII, CPP.

Por consequência, revogo a prisão preventiva. Expeça alvará de soltura clausulado. Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB

para essa espécie processual.

Oportunamente, arquivem-se.

Cópia da presente, assinada digitalmente, servirá como mandado/carta precatória/alvará/ofício/termo para as finalidades cabíveis, lembrando-se que a sua autenticidade poderá ser confirmada no endereço eletrônico do E. TJSP (www.tjsp.jus.br).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santa Bárbara d'Oeste, 21 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA